我国土地用途管制改革的法理求解

张先贵

摘 要 我国现行土地用途管制在实践运行中呈现出失灵状态，须对其作理性地检讨，并从世界观和方法论两大维度提出切实可行的改革和完善方案。综观现有理论和实践，立足于“权利—权力”平衡的规范语境，从系统论、制度联动效应等视角出发，我国现行土地用途管制改革宜践行以下“一揽子”方案：在理念上应建立多元利益诉求均衡实现的制度样态体系；在逻辑前提上应积极推动我国土地规划模式由“增量”向“存量”的转型；在关键内容上应突破现行农用地转用审批的封闭运行结构；在技术路线上应创新“两个总量指标控制”的实现方式，力争实现土地用途管制的弹性化目标；在配套跟进上应有效推进存量建设用地再开发法律制度建设。唯有如此，方可有助于突围这一制度运行失灵的困境，有助于实现十九大报告所提出的“确保国家粮食安全”这一重大战略目标。

关键词 土地用途管制 失灵 土地规划 农用地转用审批 总量指标

作者张先贵，法学博士，上海海事大学法学院副教授。

DOI:10.16094/j.cnki.1005-0221.2018.04.007

一、引言：问题与背景

土地财产权与土地管理权形塑了我国现行的土地法规范体系。当下，我国土地法律制度改革，亦主要聚集于这两大议题而展开。① 就后者而言，1998 年《土地管理法》修订时确立了土地用途管制法律制度，意义重大：一方面标志着 1986 年《土地管理法》确立的以“分级限额审批制”为核心的土地管理模式走向了终结；② 另一方面亦宣示我国以土地规划为基础、以用途分类为核心的新型土地管理模式的确立。③ 实践证明，作为协调耕地资源保护与建设用地供给二者关系的土地用

** 本文系教育部哲学社会科学重大攻关项目“农村土地股份制改革的理论探索与制度设计”（13JZD007）、国家社科基金青年项目“‘准征收’与行政补偿法律制度研究”（17CFX012）和司法部国家法治与法学理论研究项目“城市治理下容积率指标交易法律问题研究”（16SFB5012）的阶段性成果。

① 参见韩松：“论农民集体土地所有权的管理权能”，《中国法学》2016 年第 2 期，第 121-142 页；高圣平：“新型农业经营体系下农地产权结构的法律逻辑”，《法学研究》2014 年第 4 期，第 76-91 页；党国英、吴文媛：“土地规划管理改革：权利调整与法治建构”，《法学研究》2014 年第 5 期，第 57-75 页。

② 参见甘藏春：“重温《土地管理法》的全面修订”，《中国法律》2011 年第 6 期，第 38 页。

③ 参见王万茂：“土地用途管制的实施及其效益的理性分析”，《中国土地科学》1999 年第 3 期，第 10 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

途管制制度，在保护稀缺耕地资源、维护国家粮食安全方面起到了重大作用。④ 然而，伴随我国土地市场的迅速发展，土地财产权价值的极大释放，多元化市场主体利益诉求正日益凸显。带有浓厚传统计划经济色彩的土地用途管制，因践行国家本位的单向度利益调控模式，掩蔽和淡化了被管制者的利益诉求，再加上制度设计上的内在刚性等特征，致使其在实践的运行中，逐渐暴露出与社会发展不相适应的弊病。从当下我国土地管理实践来看，违反土地用途管制，从事农地非农化开发建设的违法用地现象屡禁不止，从一定意义上宣示现行土地用途管制已步入了运行失灵的困境。⑤

有鉴于此，如何改革我国现行土地用途管制，以突围这一失灵困境，自然成为当下法学理论研究所无法回避的重大议题。为此，学理上分别提出了土地用途管制“市场化改革”论、⑥ 土地用途“激励性管制改革”论、⑦ 土地用途管制“补偿改革”论⑧等治理方案。客观而言，上述三种治理方案，对于我国土地用途管制改革之推进具有一定程度的参考价值，但都不无检讨的余地。具体而方，于微观层面，三种改革方案没有为土地用途管制改革提供最为直观、具体和有效的应对路径，而存在程度不等的缺陷和硬伤。于宏观层面，三种改革方案均聚集于制度的内在结构之改进，而忽视从外部视角的切入来进行法体系的研判，并在此基础上提出系统性、联动性的应对方案，因而存在视角偏狭、立论基点单一、观点片面等弊病。此外，三种改革方案亦没有契合当下的“实验主义”改革进路，⑨ 对诸多的改革试点政策所积累的宝贵经验作积极回应。⑩ 因此，就法效果而言，三种改革方案难以真正有效地实现制度改革的目标。

由此，如何回到问题的实质层面，立足于系统论视角，从制度联动改革的顶层设计层面，提出切实可行的“一揽子”应对方案，就成为当下我国土地用途管制改革的一项重大法制课题。尤其是在十九大报告已明确提出要“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”⑪ 的背景下，对这一议题展开深入研究，就显得更富有理论意义和实践价值。

二、理念转变：建立多元利益诉求均衡实现的制度样态体系

作为“法律制定及运用之最高原理的法理念”，⑫ 不仅是对法之本质、灵魂的一种深刻诠释，

④ 参见孙佑海：“《土地管理法》的历史回顾和修改建议”，《国土资源导刊》2009 年第 11 期，第 50 页。

⑤ 参见郭洁：“土地用途管制模式的立法转变”，《法学研究》2013 年第 2 期，第 61-62 页；杨惠：《土地用途管制法律制度研究》，法律出版社 2010 年版，第 2 页；赵宁：“土地利用规划激励性管制法律制度的实现”，《社会科学辑刊》2015 年第 1 期，第 67 页。

⑥ 参见注⑤，杨惠书，第 2 页；王文刚、庞笑笑、宋玉祥：“土地用途管制的外部性、内部性问题及制度改进探讨”，《软科学》2012 年第 11 期，第 33 页；王成艳、靳相木：“土地用途管制实施机制市场取向改革探讨”，《国土资源科技管理》2009 年第 2 期，第 48 页。

⑦ 参见注⑤，郭洁文，第 60 页；徐建炜：“农地保护的国际经验及其对中国的启示”，《国际经济评论》2010 年第 2 期，第 136 页；高帆：“激励相容与农业供给侧结构性改革的实施逻辑”，《天津社会科学》2017 年第 4 期，第 99 页。

⑧ 参见靳相木、杜茎深：“耕地保护补偿研究——一个结构性的进展评论”，《中国土地科学》2013 年第 3 期，第 47 页；朱兰兰、蔡银莺：“土地用途管制下基本农田发展权受限的区域差异及经济补偿——以湖北省武汉、荆门、黄冈等地区为实证”，《自然资源学报》2015 年第 5 期，第 736 页；赵茜宇、张占录、华逸旋：“基于土地发展权的大都市郊区耕地保护——以北京市平谷区为例”，《国土资源科技管理》2015 年第 4 期，第 30 页。

⑨ 参见张玉洁：“论我国土地制度改革的实验主义进路——以 1978-2013 年土地立法为样本的分析”，《时代法学》2014 年第 2 期，第 56 页。

⑩ 参见杨玉珍：“需求诱致和体制约束下我国土地制度创新研究——兼论试点市的土地制度创新行为”，《现代经济探讨》2015 年第 4 期，第 34 页。

⑪ 习近平：“决胜全面建设小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告”，载新华网 http://www.sohu.com/a/198676567_407270，2017 年 10 月 22 日访问。

⑫ 史尚宽：“法律之理念与经验主义法学之综合”，载刁荣华主编：《中西法律思想论集》，汉林出版社 1984 年版，第 259 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

再现了法的终极意识，而且亦是法的生命之所在。因而，法的理念决定着具体的法制度和法规范之展开样态。就制度改革而言，只有首先在理念上突破旧有思维之藩篱和束缚，方可触及问题的深处和本质，进而提出兼有合理性和可行性的具体方案。⑬

就违反土地用途管制的现象，严格执行我国现行《土地管理法》等法律法规，加大对土地违法行为的处罚力度，就成为决策者、执法者处理此类问题一以贯之的思维和方法。⑭ 然而，令人遗憾的是，在十分严格的执法背景下，此类违法用地现象不仅没有得到有效遏制，反而呈现出“有禁无止”、愈演愈烈的局面。⑮

在笔者看来，加大对违反土地用途管制行为的处罚力度，乃是试图从下游层面堵住这一违法行为发生的一种思路和方法。虽然这一方法具有一定的阶段性效果，但尚未触及问题的实质——制度自身的弊病，因而难以从根本上解决我国土地用途管制运行失灵的困境。当然，在制度样态受理念形塑和支配的原理下，只有对我国现行土地用途管制这一制度的构造理念予以深入反思与检讨，方可在此基础上提出实质性的改革方案。具体而言:

一方面，在国家与农用地权利人、农村集体经济组织关系上，因现行土地用途管制的制度设计忽视了对被管制者的利益诉求，难以契合公权与私权协调、公益与私益平衡的基本法理念。一般而言，在我国现行土地用途管制下，农用地权利人只能将承包地用于农业生产而不能从事非农开发建设使用。我国《物权法》已明确将土地承包经营权规定为一项独立的用益物权，但仍然继续对农用地权利人进行单纯、无补偿的限制，明显有失公平: 其一，在土地用于农业生产和开发建设所带来的市场利润或比较效益相差悬殊的背景下，⑯ 单纯地对农用地用途进行无偿限制，而不给予受损开发利益的公平补偿，不仅难以调动被管制者自觉遵守这一制度，而且会进一步加剧城乡之间的差距; 其二，从比较法来看，在实行土地分区管制的美国等国家，对因受到限制而无法开发建设的管制区的土地权利人给予受损开发利益的公平补偿，早已成为不争的事实，只是在保护方式上存在“公共地役权”⑰“管制征收补偿”⑱ 以及“土地发展权交易”⑲ 等不同模式而已。

另一方面，在中央和地方关系上，因现行土地用途管制的制度设计对地方政府独立的利益诉求未作积极回应，⑳ 难以激励地方政府自觉遵守和执行这一制度。从我国《土地管理法》等法律法规的规定来看，中央政府和地方政府构成了我国土地用途管制权的行使主体。在二者的权力配置方面，地方政府乃是在中央政府的授权下行使对本区域土地资源实施管理。㉑ 因此，理论上，地方政府应严格按照中央政府设定的目标来管理本区域的土地资源，以保护好稀缺的耕地资源、维护好国家的粮食安全。然而，从实践来看，受“土地财政”等多种因素的影响，将大量农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设，已经成为地方政府发展本地经济的重要方式。尤其是在现有技术条

---

⑬ 参见李龙“中国特色社会主义法治体系的理论基础、指导思想和基本构成”，《中国法学》2015 年第 5 期，第 19-20 页。

⑭ 参见程雪阳“中国的土地管理出了什么问题”，《甘肃行政学院学报》2013 年第 3 期，第 108 页。

⑮ 参见何艳玲“中国土地执法摇摆现象及其解释”，《法学研究》2013 年第 6 期，第 61 页。

⑯ 参见耿卓“农地三权分置改革中土地经营权的法理反思与制度回应”，《法学家》2017 年第 5 期，第 14 页。

⑰ See Nancy A. McLaughlin, “Increasing the Tax Incentives for Conservation Easement Donations-A Responsible Approach”, *Ecology Law Quarterly*, Vol. 31, No. 1 (2004), p. 4.

⑱ See Madelyn Morris & Mary Griffin, “Regulatory Taking Claims in Massachusetts”, *Massachusetts Law Review*, Vol. 82, No. 2 (1997), p. 246.

⑲ See Ari D. Bruening, “The TDR Siren Song: The Problems with Transferable Development Rights Programs and How to Fix Them”, *Journal of Land Use & Environmental Law*, Vol. 23, No. 2 (2008), pp. 423-440.

⑳ 参见容志《土地调控中的中央与地方博弈》，中国社会科学出版社 2010 年版，第 238 页。

㉑ 参见刘俊、朱小平“国有土地所有权权利行使制度研究”，《江西社会科学》2012 年第 1 期，第 147 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

件、土地资源约束以及区域之间竞争日益加剧的背景下，这一方式显得更为明显。[22] 就此而言，地方政府具有土地资源经营者与管理者的双重角色。作为经营者，其享有独立的利益诉求。然而，现行土地用途管制的制度设计却忽视了地方政府独立的利益诉求。这是实践中许多地方政府不严格执行甚至直接违反土地用途管制的重要原因。

实际上，自改革开放以来，伴随我国市场经济的不断发展，由市场所催生出的多元化主体具有明显、独立且正当的利益诉求。虽然这些多样化的利益诉求，有的因具备了类型化基础而上升为一项独立的实定法权利;[23] 有的尚未转化为实定法权利而仅处于理论上的论证阶段。[24] 但一个不争的事实是，借助于法律制度的构造来回应这些多元化的利益诉求，已成为各部门法领域的普遍现象。然而，令人遗憾的是，如何改革我国现行土地管理制度，以积极回应多元化主体的利益诉求，似乎显得较为迟钝，或者说没有受到应有的重视。由于受传统计划经济的影响，恪守国家利益本位的土地用途管制，一方面与当下的行政法理论所倡导的“激励性管制”原理相悖，[25] 难以实现管制者与被管制者之间的相互配合、相互协作，难以调动被管制者自觉遵守这一制度；另一方面会在一定程度上抑制各类土地市场的顺利发展，从而最终阻碍社会的进步。

是故，基于对实践的深刻反思，跳出传统理念之窠臼，将多元主体的利益诉求嵌入制度结构规范中，建立多元化利益诉求均衡实现的制度样态体系，是我国现行土地用途管制改革应践行的正确理念。

三、逻辑前提：积极推动我国土地规划模式由“增量”向“存量”之转型

从实定法来看，虽然将农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设会受到严格的限制，但在城镇化快速发展的当下，大量的农业人口向城市转移、大量的耕地资源被转为建设用地从事非农开发建设不可避免。如何协调好耕地资源保护与建设用地供给二者间的关系，一直成为我国土地管理中的难点和焦点。[26] 为此，担当我国土地管理龙头的土地规划制度，立足于当下的客观实践，基于历史和逻辑的双重考量，确立了以保护稀缺耕地资源、严控建设用地供给为基本目标。[27] 为实现这一目标，在具体的路径和技术选择上，主要是借助于指标这一可量化的数字形式对耕地保有量和新增建设用地总量进行了较为严格的控制。具体而言，中央政府在编制土地利用总体规划时，一次性确定全国中长期（一般是 10-15 年）的新增建设用地总量控制指标，然后通过“总量控制、统一分配、层层分解、指令性配额管理”的模式自上而下由中央下达地方。各地方政府所取得的新增建设用地总量指标可作为规划期内农用地转为建设用地的依据。当然，以上仅是针对规划期内农用地转为建设用地的制度安排，而对于年度内农用地转为建设用地，则主要是由土地利用年度计划来调整，其运作原理与土地利用总体规划相类似。

---

[22] 参见孙秀林、周飞舟：“土地财政与分税制：一个实证解析”，《中国社会科学》2013 年第 4 期，第 40 页。

[23] 参见孙山：“寻找被遗忘的法益”，《法律科学》2011 年第 1 期，第 59 页。

[24] 参见姚建宗：“新兴权利论纲”，《法制与社会发展》2010 年第 2 期，第 9-11 页。

[25] 参见刘华涛：“论政府激励性管制过程”，《行政论坛》2012 年第 4 期，第 32 页；丰霏：“当代中国法律激励的实践样态”，《法制与社会发展》2015 年第 5 期，第 181 页。

[26] 参见范树平、刘友兆、程从坤：“中国土地管理制度困境及改革路径研究——基于 Williamson 分析框架”，《中国国土资源经济》2016 年第 4 期，第 60 页。

[27] 参见姜志法、刘双良：“土地规划中新增建设用地指标分解理论与方法”，《中国房地产》2009 年第 8 期，第 54 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

就此而言，地方政府在年度范围内能否将本辖区的农用地转为建设用地，关键取决于其是否获得自上而下所分配的农用地转用指标。换言之，持有农用地转用指标是地方政府变更农用地用途管制的先决条件。就上述指标管制模式，学理上的诟病较多、批判之声一直尚存。譬如，有学者指出，“因信息不对称的存在，对新增建设用地的管理采取指标式的自上而下的分配模式，导致了各地指标的分配存在明显的苦乐不均现象，不利于经济的整体发展”；[28] 亦有学者指出，“因是否持有农用地转用指标直接决定能否将农用地转为建设用地，并且持有指标的多少直接决定农用地转用的数量和规模，因此，在土地财政的诱因下，为推动本地经济的发展，地方政府往往会采取各种虚报、瞒报等违法行为，骗取中央政府分配更多的农用地转用指标，显然这会使大量的耕地资源遭到破坏”。[29] 另外，针对其存在的信息不对称，虚报、瞒报等违法行为，学理上亦提出了相应的对策。但令人遗憾的是，实践成效不够理想，各种违反用地指标管制的违法用地现象依然有增无减。[30]

由此而来的问题是，作为土地用途管制基础的土地利用总体规划制度，究竟如何改革，方可较好地协调耕地资源保护与建设用地供给二者间的关系，从而最终实现土地用途管制的有效运行。在笔者看来，要从根本上解决我国现行土地规划制度存在的实质性问题，更好地实现稀缺耕地资源保护的目标，须立足当下我国城镇化发展的客观实际，积极推动我国土地规划模式由“增量”向“存量”之转型。[31] 究其缘由，可从以下三方面予以解释:

其一，积极推动我国土地规划模式由“增量”向“存量”的转变，是由我国城市从外延式扩张向内涵式发展所决定的。从改革开放三十多年来的发展看，我国的城市已经形成了固定的增长模式，即以政府主导的方式组织市场要素（土地、资本、劳动力、原材料、技术等）实现城市的高速发展。[32] 在诸多的发展要素中，土地的投入对中国经济增长的贡献率最大，[33] 或者说我国的经济发展呈现出明显的“以消耗土地为主要特征”的发展模式。[34] 在这一背景下，我国的土地规划主要践行的是“增量”模式，即保障城镇建设用地的合法、及时的供应构成了这一规划行使的主要目标。客观而言，这种外延式城市扩张模式确有其明显的优点，即在城镇化的早期，吸引了大量的农业人口、快速地推动了产业集聚，从而加快了我国城镇化的快速发展。但伴随着我国城镇化发展到一定阶段后，其弊病亦日益明显。具体而言，这种“摊大饼式”的城市扩张模式，因过于追求城市的平面扩张而使得“土地的城镇化速度明显快于人口的城镇化速度”，[35] 导致了大量通过征收取得的土地处于闲置、浪费状态。[36] 这不利于土地资源的优化配置，并且与耕地资源保护的精神背道而驰。与此相对应的是，内涵式的城市发展模式则强调的不再是将城镇土地扩张作为城市经济增长的主要动力或基础，而是转向对现有的土地等生产要素进行功能调控和再分配。概言之，提高现有用地效率和用地质量是这一发展模式的实质诉求。

其二，积极推动我国土地规划模式由“增量”向“存量”的转变，是改革我国现行征地制度，

㉘ 郭杰、包倩、欧名豪 “基于资源禀赋和经济发展区域分异的中国新增建设用地指标分配研究”，《中国土地科学》2016 年第 6 期，第 72-73 页。

㉙ 孙静静、师学义 “新增建设用地指标分解中县级政府间博弈分析——基于‘公地悲剧’和‘囚徒困境’的视角”，《广东土地科学》2012 年第 3 期，第 44-45 页。

㉚ 参见曾志敏 “地方土地利用与开发的双重困境及治理”，《宏观经济管理》2017 年第 4 期，第 62 页。

㉛ 在规划学上，基于规划的流变以及不同特征，存在“增量规划”“存量规划”“减量规划”三种不同类型。参见陈宏胜、王兴平、国子健 “规划的流变——对增量规划、存量规划、减量规划的思考”，《现代城市研究》2015 年第 9 期，第 45-47 页。

㉜ 参见注㉛，第 45 页。

㉝ 参见王建康、谷国锋 “土地要素对中国城市经济增长的贡献分析”，《中国人口·资源与环境》2015 年第 8 期，第 10 页。

㉞ 参见谭明智 “严控与激励并存：土地增减挂钩的政策脉络及地方实施”，《中国社会科学》2014 年第 7 期，第 125 页。

㉟ 参见肖金成 “人的城镇化：新型城镇化的本质”，《探索与争鸣》2013 年第 11 期，第 17 页。

㊱ 参见刘云生 “农村土地征收三大命题证伪”，《甘肃社会科学》2010 年第 6 期，第 166 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

减少当事人之间矛盾，节约集约利用土地资源的内在诉求。从我国土地管理的历史变迁与现实来看，在三十多年的“增量规划”背景下，大量的农用地被征收转为建设用地从事农地非农化开发建设，并引发了诸多的社会矛盾以及耕地资源流失等问题。在反思现行土地征收存在的诸多问题时，几乎将所有的目光聚集于“公共利益”“征收补偿”以及“征收程序”三要件上，并围绕这三个方面展开了大量的研究。[37] 客观而言，虽然上述研究对完善我国现行土地征收法律制度、规范政府土地征收权的行使具有重要的理论指导价值，但令人遗憾的是，当下我国的土地征收实践仍然不容乐观，即围绕土地征收权行使所引发的纠纷以及带来的土地资源浪费现象仍然成为社会的严重问题。[38] 由此而引发的思考是，问题的根源何在？

在笔者看来，要想根本上解决我国现行土地征收问题，亟须认识到我国土地规划法律制度的龙头地位，并将现行土地规划制度的改革作为我国征地制度改革的突破口或切入口。具体而言，虽然现行法规定公共利益需要乃是启动土地征收的前提要件，但从我国的土地征收实践来看，政府能否对本区域具体地块行使土地征收权，关键是看其是否有规划依据。[39] 换言之，一旦本区域的农用地被纳入规划区，那么将其征收转为建设用地从事农地非农化开发建设就具有了正当性依据，此时的公共利益需要被以规划需要所替代。依此实践逻辑，决定土地征收权行使的根本依据乃是规划。当然，这一方面凸显了土地规划的龙头地位，另一方面说明了改革我国现行土地规划法律制度乃是突围我国现行土地征收权行使困境的根本之策。是故，在这一背景下，转变我国现行土地规划模式，积极推动其从“增量”向“存量”的转变，对缩小我国当下的征地范围和规模、降低征地速度，缓解征收当事人之间的矛盾，保护稀缺的耕地资源，意义重大。

其三，积极推动我国土地规划模式由“增量”向“存量”的转变，不仅符合规划模式流变的内在规律，而且亦是转变我国当下土地利用方式，实现社会经济可持续发展的现实需要。从域外经验来看，从早期的“增量规划”向“存量规划”再向“减量规划”的模式转变，构成了规划模式流变所遵循的基本规律。[40] 这对处于新型城镇化下的城乡关系面临转型的我国亦不例外。前文已述，自改革开放三十多年来，我国的土地规划践行的乃是“增量规划”模式，学理上将这一阶段称为“增量规划繁荣”时期。[41] 然而，伴随土地资源的日益紧缺，新增建设用地指标供给的日益受限，再加上经济的粗放式发展、环境污染的日益严重以及产业链的低端等因素，使传统的“增量规划”模式已难以解决诸如此类的社会问题，迫切需要转型，即探索“存量规划”模式，这在我国部分城市已有实践，并积累了一定的宝贵经验。[42]

此外，减少土地资源的供应，积极推动我国土地规划模式由“增量”向“存量”的转变，对现有的城市建设用地进行大力整治，以提高其开发利用强度，亦是我国土地利用方式从注重平面利用的一元模式向兼顾平面利用与立体利用的二元模式转变的内在要求。[43] 土地利用方式主要包括平

---

[37] 参见王克稳：“我国集体土地征收制度的构建”，《法学研究》2016 年第 1 期，第 56-72 页；崔建远：“征收制度的调整及体系效应”，《法学研究》2014 年第 4 期，第 63-75 页；陈小君：“农村集体土地征收的法理反思与制度重构”，《中国法学》2012 年第 1 期，第 33-44 页。

[38] 参见刘云生、李晓伟：“农民土地维权行动方式考察及法律对策研究”，《法律科学》2011 年第 3 期，第 178 页。

[39] 参见刘玉姿：“征收的规划控制”，《城市规划》2015 年第 8 期，第 56 页；张墨宁：“土地征收背后的规划之弊”，《南风窗》2011 年第 21 期，第 68 页。

[40] 参见施卫良：“规划编制要实现从增量到存量与减量规划的转型”，《城市规划》2014 年第 11 期，第 21-22 页。

[41] 参见注[31]，第 47 页。

[42] 参见邹兵：“存量发展模式的实践、成效与挑战——深圳城市更新实施的评估及延伸思考”，《城市规划》2017 年第 1 期，第 89-94 页；王皓、薛虎：“由增量向存量规划转型下的城市更新策略——以海口市主城区更新为例”，《中外建筑》2017 年第 1 期，第 68-70 页；关烨、葛岩：“新一轮总规背景下上海城市更新规划工作方法借鉴与探索”，《上海城市规划》2015 年第 3 期，第 33-38 页。

[43] 参见史平平、张军连、杨燕敏：“我国城市地上地下土地权利的设立——以中关村西区为例”，《自然资源学报》2010 年第 10 期，第 1639-1648 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

面利用和立体利用两方面内容，由于受科学技术等条件的限制，传统土地利用方式更注重的是平面利用。然而伴随科学技术的迅速发展，以及土地资源的日益稀缺，土地立体利用方式逐渐受到重视。如何提高现有土地开发利用强度已成为土地资源配置所无法回避的客观现实。[44]

综上所述，积极推动我国土地管理模式从“增量”向“存量”之转变，是保护我国稀缺耕地资源、维护国家粮食安全的重大战略性选择，这构成了我国土地用途管制改革的逻辑前提。

四、关键内容：突破现行农用地转用审批程序的封闭运行结构

从 1986 年以来我国土地管理法律制度的变迁历程来看，虽然具体的制度不断地调整和改革，但其背后逻辑始终是为了解决一个中心命题：如何协调好耕地资源保护与建设用地供给二者间的关系。前者解决的是吃饭问题，而后者解决的是经济发展问题。可以说，究竟是以耕地资源保护为主，还是以建设用地供给为主，一直是我国土地管理法律制度改革的重心。从 1986 年《土地管理法》确立的“分级限额审批制”到 1998 年《土地管理法》确立的土地用途管制，旗帜鲜明地体现了我国土地管理制度践行的是以耕地资源保护为主、严格限制农用地转为建设用地从事农用地非农化开发建设的指导思想。从理论上讲，这一指导思想是正确的，但从实践来看，立足我国现阶段的国情，将大量农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设，又成为我国当下经济发展的重要方式。

有鉴于此，为平衡国家粮食安全和经济发展的双重诉求，我国现行《土地管理法》在土地用途管制的制度设计上，针对农用地转为建设用地设置了较为严格的农用地转用审批程序，即地方政府在征收集体土地时，如涉及农用地，在向省级政府或者国务院办理土地征收审批程序时，还需要办理此一程序。这一程序的设立目的主要在于保护稀缺的耕地资源。前文已述，地方政府能否将农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设，主要取决于其是否持有新增建设用地指标。这一指标乃是中央政府通过自上而下的方式层层分解的结果。实践中，国务院或者省级人民政府在决定是否赋予地方政府农用地转用权，也主要看其是否持有农用地转用指标（新增建设用地指标）。[45]

客观而言，我国现行农用地转用审批程序，在执行我国现行土地用途管制、保护耕地资源方面曾发挥着重要的功能。但因其内在的缺陷，亦广为学界所诟病，尤其是在我国现行土地用途管制已步入运行失灵的困境下，这一批判之声更是尖锐和强烈。譬如，许多学者认为，自 1998 年《土地管理法》将农用地转用审批权上收至省级人民政府和国务院后，造成农用地转用审批程序更为严格、程序运行成本较高且缺乏效率。实践中，地方政府采取各种方式来规避这一程序，致使其形同虚设，为此，应亟须“下放审批权至县、市人民政府”。[46] 此外，在现行农用地转用审批程序运行中，因过于关注量化指标，一方面诱发地方政采取各种规避法律的违法方式获取新增建设用地指标，从而将大量的优质农用地转为建设用地，造成了大量的耕地资源减少；[47] 另一方面，虽然通过

---

[44] 参见张先贵：“容积率指标交易法律性质及规制”，《法商研究》2016 年第 1 期，第 63 页；赵亚莉、刘友兆：“城市土地开发强度差异及影响因素研究——基于 222 个地级及以上城市面板数据”，《资源科学》2013 年第 2 期，第 380-387 页。

[45] 在农用地转用审批程序中，强调对指标数量的审查，而淡化对程序的审查乃是其显著特点。参见邹爱华：“完善土地征收审批制度的基本思路与具体对策”，《国家行政学院学报》2011 年第 2 期，第 95 页。

[46] 参见注[45]，邹爱华文，第 96-97 页；陈书荣、陈宇：“土地审批制度的供给侧改革：征批分离”，《中国土地》2016 年第 2 期，第 23 页。

[47] 参见胡初枝：“农地转用乱象及规范途径”，《中国土地》2010 年第 5 期，第 47-48 页；叶七玲：“农用地转用补偿及补偿制度改革探析”，《浙江国土资源》2016 年第 3 期，第 39-40 页；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

土地开发整理指标填补了农用地转用指标的需求，即形式上满足了耕地保护数量（即耕地保有量指标）的要求，但却忽视了对优质耕地资源质量和生态价值的保护，无形中增加了大量的社会成本，不符合比例原则，为此，应亟须转变这一做法，严格限制指标的获取和行使。[48]

在笔者看来，上述所提出的简化农用地转用审批程序、提高审批效率、降低审批程序运行成本以及严格限制农用地转用指标的获取和行使等改革建议，顺应了当下我国行政审批制度改革的趋势，[49] 具有重要的理论意义和实践价值，均值得肯定。但若深入检视，不难发现，上述改革方案，都是在没有突破我国现行农用地转用审批程序的封闭结构下所进行的有限度之改革，其成效难有实质性进展。进言之，引入第三方监督机制，突破这一程序运行的封闭结构，应是助推这一程序步入理性轨道的应然诉求。

其一，建立地方人大对农用地转用预审批程序。现行农用地转用审批程序下，国务院或者省级人民政府对地方政府（主要是县、市人民政府）报批的农用地转用材料行使审批权时，主要审查的是其是否持有农用地转用指标，如果地方政府持有符合规划和计划所分配的农用地转用指标，那么获得农用地转用审批是当然的。在此情形下，行政机关内部上下级之间行政审批所带来的信息封闭的弊端，使得这一程序内部存在诸多虚报隐瞒、造假、欺骗等违法现象，从而导致大量的耕地资源被非法转为建设用地。为此，理性的做法应是，建立地方人大对农用地转用的预审批程序。这一方面体现了代表民意的权力机关对行政机关的监督，有助于规范行政机关的权力行使；另一方面，亦符合我国《宪法》的规定。“审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划”是地方人大的重要职权之一。能否将农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设属于地方经济建设的重要内容，地方人大理应享有相应的审查和决定权。

其二，建立对农用地转用审批行为的司法审查机制，充分发挥法院对政府行政审批程序的审查监督作用。根据《行政诉讼法》第 12 条第 5 项之规定，“对征收、征用决定及其补偿决定不服的，可以向法院提起诉讼”。前文已述，现行法上，对于农用地转为建设用地从事非农开发建设需要办理农用地转用审批和土地征收审批两项程序（仅限于分批次征地模式[50]）。土地征收决定乃是农用地转用审批的后续程序。基于目的性扩张和类推等解释方法，既然立法上已赋予土地征收审批程序下的土地征收决定具有可诉性，那么与之类似的农用地转用审批程序下的农用地转用决定亦应具有可诉性，即针对农用地转用审批决定而产生的争议应成为法院的受案范围。

其三，建立拟转用农用地权利人的意见表达机制。将农用地转为建设用地，不仅造成耕地资源的减少、影响国家的粮食安全，而且对农用地权利人的农地经营权也会带来相应的影响。[51] 因此，建立拟转用农用地权利人的意见表达机制，充分利用各种途径，为农用地权利人提供表达意见的机会，打破农用地转用程序的封闭状态，不仅是落实农地权利人的知情权、[52] 推动农用地转用审批程序正当性建设的内在要求，而且有助于审批机关综合权衡各种因素，从而作出是否转用的决定。这对减少地方政府各种违规报批行为的发生亦具有重要的预防作用。从实践来看，采用正式的听证会

---

[48] 参见马韬：“农转用年度计划管理制度尚需完善”，《中国土地》2012 年第 1 期，第 27 页；王良健、韩向华、李辉、罗宁波：“土地供用绩效评估及影响因素的实证研究”，《中国人口·资源与环境》2014 年第 10 期，第 121 页。

[49] 参见王克稳：“论行政审批的分类改革与替代性制度建设”，《中国法学》2015 年第 2 期，第 5-28 页。

[50] 我国现行土地征收主要包括“项目征地”和“分批次征地”两类模式，两审批模式主要适用于“分批次征地”模式。参见欧阳君君：“完善征地制度须改革征地权的纵向配置模式”，《法学》2016 年第 5 期，第 152 页。

[51] 关于土地经营权相关内容，参见高圣平：“承包土地的经营权抵押规则之构建——兼评重庆城乡统筹综合配套改革试点模式”，《法商研究》2016 年第 1 期，第 3-12 页。

[52] 参见邹爱华：“土地征收中的被征收人知情权保护”，《法律科学》2012 年第 6 期，第 118 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

形式或书面的意见审查形式，乃是较为常见的做法，这些均值我国当下《土地管理法》修改时借鉴。

五、技术路线：创新“两个总量指标控制”的实现方式

通过指标的形式，严格控制“耕地保有量”和“建设用地总量”是我国现行土地用途管制在协调耕地资源保护与建设用地供给二者关系上所践行的主要技术路线。[53] 为此，在我国现行《土地管理法》等法律法规上，分别围绕“耕地保有量的指标控制”和“建设用地总量的指标控制”展开了诸多的制度设计和规范配置。[54] 然而，从实践功效来看，各地区在执行指标总量控制方面不尽如人意，突破“两个总量指标控制”的违法用地现象经常发生。这亟须我们认真反思现行“两个总量指标控制”的制度安排，并在此基础上作出相应的制度创新。

具体而言，尽管上文已就农用地转用审批程序结构之改革提出诸多建议，但一个不可回避的事实是，我国幅员辽阔，各地区经济发展水平差异较大，土地利用总体规划和土地利用年度计划事先所设定的指标，往往难以契合和满足各地经济发展的现实需要。实践中，各地因指标分配的“苦乐不均”现象比比皆是，这在经济发达地区与经济欠发达地区表现得尤为明显。经济发达地区因工商业的发展对土地的需求十分旺盛，将大量的农用地转为建设用地已成为经济发展的主要方式，但因其所分配的指标十分有限，如何解决指标的有限性与经济发展对指标需求的无限性之间的矛盾一直成为土地管理中的一道现实且复杂的难题。[55] 在面对这一难题时，地方政府无外乎有两种选择：一是严格遵守“两个总量指标控制”的制度安排；二是在经济发展的压力下，突破现行“两个总量指标控制”制度安排，违法实施农用地转为建设用地。从实践来看，在现行“土地财政”和“晋升锦标赛”等因素影响下，上述第二种情形成为许多地方政府的主要选择。[56] 由此，对于地方政府违反我国现行土地用途管制的原因似乎亦就不难理解了。

当然，这随之而来的问题是，面对地方政府违反农用地用途管制，实施突破“两个总量指标控制”的违法行为，是否意味着需要废除现行“两个总量指标控制”的法律制度安排呢？如果继续坚持的话，那么又如何对现行“两个总量指标控制”制度的实现方式进行创新？显然，这是从系统论视角改革我国现行土地用途管制所无法回避的重大现实难题。

在笔者看来，对于第一个问题，无论是从理论还是从实践来看，都不应否认现行“两个总量指标控制”法律制度存在的正当性。一方面，借助指标这一数字化形式来确定耕地资源的保有量和新增建设用地的总量，是克服我国现行土地管理制度自身的模糊性，有效规范土地管理中的自由裁量权，实现土地管理的秩序化、科学化和精确化的内在要求；[57] 另一方面，指标这一数字量化机制所具有的格式化特征与我国土地管理法律制度所追求的客观性不谋而合。借助指标这一数字化形式可

---

[53] 参见马永欢、张丽君、黄先栋：“确立我国土地管理红线的战略思考”，《中国软科学》2014 年第 1 期，第 29-35 页。

[54] 参见徐绍史：“健全严格规范的农村土地管理制度”，《理论参考》2009 年第 1 期，第 30-33 页。

[55] 参见曹亚鹏：“‘指标漂移’的社会过程——一个基于重庆‘地票’制度的实证研究”，《社会发展研究》2014 年第 2 期，第 55-57 页。

[56] 参见高峰、师学义：“建设用地指标配置的需求意愿分析”，《中国社会科学院研究生院学报》2011 年第 3 期，第 66 页。

[57] 借助指标这一数字形式来规范我国现行土地管理权的行使，是我国现行土地管理法律制度设计上的重大创新，无论是土地管理中的数量红线、质量红线还是生态红线，均是其鲜明的体现。参见注[53]，马永欢等文，第 29 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

保障我国土地管理制度的可操作性，这是由数字的工具功能所决定的。[58] 就此而言，指标这一数字形式赋予了土地管理法律的科学性、客观性以及正当性。此外，现行“两个总量指标控制”法律制度安排在我国现行土地管理制度中具有基础性地位，其变动或调整往往牵一发而动全身，或者说，其法体系效应十分显著。因此，基于制度改革的成本、风险以及长期的路径依赖惯性等因素考量，废除现行“两个总量指标控制”的法律制度安排不具有合理性和可行性。

在证成了“两个总量指标控制”的法律制度安排具有正当性后，接下须回答的问题是，对地方政府违法变更农用地用途管制，实施突破“两个总量指标控制”的违法行为如何解释呢？在笔者看来，对这一问题的关注，恰恰暴露出我国现行“两个总量指标控制”制度在实现方式上存在明显的缺陷，亟须创新。当然，这亦回答了上述第二个问题。

具体来讲，在市场经济背景下，无论是企业、农民、集体经济组织，还是地方政府等主体都具有独立的利益诉求。只不过相对于其他主体的利益诉求而言，地方政府的角色颇为特殊，其不仅承担执行中央政策的职责，而且亦要承担发展本地经济的重任。是故，集政策执行职责和经济发展重任于一体的地方政府具有明显的双重角色。长期以来，对于中央政府而言，要求地方政府严格执行中央所制定的方针政策，以达到中央政府与地方政府目标函数上的一致性，乃是中央政府最希望实现的理想状态。然而，鉴于发展本地经济的现实考量，地方政府往往对中央政府制定的方针政策保持某种“选择性执行”甚至违法执行的状态。[59] 土地用途管制领域即是典型例证，在地方政府面临发展本地经济的利益驱动下，冲破指标的约束，违法实施土地用途变更行为时，中央政府往往采取的一贯处理思路是以“堵”为主，并为此而颁布了一系列严格土地管理的决定、通知等文件。[60] 然而，令人遗憾的是，实践效果与政策目标之间的反差却十分鲜明。在笔者看来，处理这一疑难复杂问题，应转变思路，化“堵”为“疏”，即在承认地方政府具有独立利益诉求的基础上，在指标计划分配外再借助市场机制为地方政府获得一定额度的指标，以解决其在经济发展中所遇到的指标不足这一难题，实乃明智之举。

这从我国当下的改革实践中可得以验证。具言之，从早期的“土地换保障”、城乡建设用地“增减挂钩”发展到后期的“地票”交易等试点政策模式，其演进逻辑的背后乃是在承认地方政府具有独立利益诉求的基础上，创新地借助市场机制为地方政府获得规划外指标创造便利。[61] 尽管这些试点方案尚存一些问题，但其积极功效不可否认。目前，这些试点方案已被作为示范样本在许多地方积极推广。[62] 实际上，传统藉由自上而下的方式分配给地方政府的有限用地指标，其本质上乃是借助单一的计划方式来实现“两个总量指标控制”的制度目标。而对于“地票”交易等试点方案，其本质上乃是在指标传统计划或行政配置机制之外，另行创造出来的市场获取指标的方式。另外，相对于“土地换保障”、建设用地“增减挂钩”两大模式而言，学理上一般认为，当下的“‘地票’交易模式乃是借助市场机制获得规划外指标的高级形态”。[63]

---

[58] 参见曲笑飞：“法律数字化现象研究”，《法律科学》2013 年第 1 期，第 30 页。

[59] 参见注[15]，何艳玲文，第 61 页；戴治勇：“选择性执法”，《法学研究》2008 年第 4 期，第 28 页。

[60] 参见周介铭：“严格贯彻落实中央文件精神确保耕地保护取得显著成效”，《资源与人居环境》2017 年第 7 期，第 6-7 页。

[61] 参见周立群、张红星：“农村土地制度变迁的经验研究：从‘宅基地换房’到‘地票’交易所”，《南京社会科学》2011 年第 8 期，第 77 页。

[62] 目前，我国许多地方已开展了类似“地票”交易的试点政策。参见刘澄宇、龙开胜：“集体建设用地指标交易创新：特征、问题与对策——基于渝川苏浙等地典型实践”，《农村经济》2016 年第 3 期，第 27 页。

[63] 文兰娇、张安录：“地票制度创新与土地发展权市场机制及农村土地资产显化关系”，《中国土地科学》2016 年第 7 期，第 33 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

鉴于此，在笔者看来，本着对试点改革方案所积累的宝贵经验的积极回应，改革我国现行土地用途管制的技术路线应是，创新“两个总量指标控制”制度的实现方式，以实现我国土地用途管制的弹性化目标。综合考量当下的现实，“地票”交易乃是实现这一方式创新“最不坏”的选择。鉴于现行实定法上还尚未将这一政策实践所积累的宝贵经验藉由权利义务的逻辑主线展开系统性的制度设计和规范配置。故当务之急，应是对“地票”交易相关问题展开系统性法律制度设计，以更好为这一新生事物有效运行提供坚实的法制保障。[64]

六、配套跟进：有效推进存量建设用地再开发法律制度建设

从我国现行的地权结构配置形态来看，对于农用地转为建设用地，主要表现为两种类型：一是农用地转为集体建设用地。根据我国现行法的规定，这里的集体建设用地主要包括宅基地、乡（镇）企业用地、乡（镇）村公共设施与公益事业用地等；[65] 二是农用地转为城镇建设用地。

从实践来看，自改革开放以来，我国城镇化迅速发展的历程，其本质上是大量农用地转为城镇建设用地的过程。相对于农用地转为集体建设用地而言，农用地转为城镇建设用地无疑构成我国现行农用地用途变更的主要类型。[66] 但从整个国土资源面积来看，对于农用地转为集体建设用地所占的数量亦不容小觑。长期以来，在“增量规划”模式的指导下，受多种因素影响，我国的建设用地呈现过度扩张、低效利用的局面。就其具体表现而言，主要体现在以下三种类型：一是各种或大或小城市的大广场、宽马路、超豪华的政府办公大楼；二是工业园区用地的不集约、不节约，各种级别的开发区、工业园区大量由政府以各种优厚条件招商引资前来的企业占用大面积土地，有的占而不用，造成土地浪费；三是农村宅基地的不集约、不节约，各地超标的农民盖房，占用大量土地，尤其在一些农村，一般将农民盖别墅作为提高农民福利的方式，也显示出土地的不集约、不节约利用。[67] 这些低效利用的建设用地，一般称为“存量建设用地”。[68]

面对这些低效利用的建设用地，通常来讲，正确的做法应是从再开发角度来提高其利用强度，以充分提高其经济效应，从而实现资源的优化配置目标。这不仅对保护稀缺的耕地资源、节约和集约土地资源具有重要意义，而且亦是顺应“增量规划”向“存量规划”的模式转变、严格执行我国现行土地用途管制的现实需要。可以说，改革我国现行土地用途管制法律制度，离不开对实践中所存在的大量存量建设用地的再开发。从一定意义上讲，有效推进存量集体建设用地的再开发乃是我国土地用途管制改革的配套制度。

有鉴于此，实践中许多地方已对存量建设用地再开发开展了大量的试点工作。关于主要试点省市，试点内容，代表性地方法规、政策以及产权类型等内容详见下表 1。

---

[64] 目前学理上围绕“地票”交易的性质、规制等法律问题展开了相应研究，但现有成果较为匮乏，且尚存争议。参见黄忠：《地票交易的地役权属性论》，《法学》2013 年第 6 期，第 15-25 页；张先贵：《地票交易之地役权属性的理性检视》，《社会科学研究》2016 年第 1 期，第 112-116 页。

[65] 参见《土地管理法》第 43 条第 1 款。

[66] 参见袁方成、康红军：“新型城镇化进程中的‘人—地’失衡及其突破”，《国家行政学院学报》2016 年第 4 期，第 47 页；钱忠好、牟燕：“征地制度、土地财政与中国土地市场化改革”，《农业经济问题》2015 年第 8 期，第 8 页。

[67] 参见刘守英：“集体土地资本化与农村城市化——北京市郑各庄村调查”，《北京大学学报（哲学社会科学版）》2008 年第 6 期，第 129-130 页。

[68] 参见王权典：《新型城镇化存量土地再开发之调控与规制策略》，知识产权出版社 2015 年版，第 56-57 页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1

试点省市	主要内容	代表性地方法规、政策	产权类型
成都	“拆院并院”、集体建设用地通过交易平台流转	《成都市集体建设用地使用权流转管理办法》《成都市“拆院并院”工作实施细则》《成都市人民政府关于完善土地交易制度促进农村土地综合整治的意见（试行）》	存量集体建设用地
嘉兴	“两分两换”	《关于开展统筹城乡综合配套改革试点的实施意见》《关于推进农房改造集聚加快现代新市镇和城乡一体新社区建设的意见》	存量集体建设用地
广东	“三旧”改造	《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于“三旧”改造工作实施意见的通知》	存量集体、国有建设用地
深圳	土地整备、城市更新	《深圳市城市更新办法》《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》《深圳市城市更新办法实施细则》《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》	存量国有建设用地、拟征收的集体建设用地
浙江	“三改一拆”	《浙江省人民政府关于在全省开展“三改一拆”三年行动的通知》《浙江省人民政府关于全面推进城镇低效用地再开发工作的意见》	存量集体、国有建设用地

从上表不难看出，围绕存量建设用地再开发活动存在诸多不同的类型，但对这些不同类型的再开发试点模式进行调整的主要是各地颁布的政策和政府规章等文件。在笔者看来，我国存量建设用地再开发活动牵涉到方方面面，譬如，再开发的指导思想如何定位？再开发的法律性质如何定位？谁来再开发？再开发的法律风险何在？如何对其风险进行法律上的规制？再开发活动中牵涉到的权利变动如何调整？等等，诸多问题，不一而足。就此而言，对存量建设用地再开发进行专门性立法，即在现阶段由国务院制定统一的《存量建设用地再开发条例》来调整和规制此类行为，宜是较为理性的选择。至于《存量建设用地再开发条例》如何制定，因牵涉的法律问题较多，容笔者另文详论，于此不再赘述。

【主要参考文献】

1. 耿卓：“农民土地财产权保护的观念转变及其立法回应——以农村集体经济有效实现为视角”，《法学研究》2014 年第 5 期。

2. 杨一介：“论集体建设用地制度改革的法理基础”，《法学家》2016 年第 2 期。

3. 丁轶：“承包型法治：理解‘地方法治’的新视角”，《法学家》2018 年第 1 期。

4. John M. Winters, “Environmentally Sensitive Land Use Regulation in California”, *San Diego Law Review*, Vol. 10, No. 4 (1973).

5. Daniel P. Selmi, “The Contract: Transformation in Land Use Regulation”, *Stanford Law Review*, Vol. 63, No. 3 (2011).

（责任编辑：高圣平）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

shareholder meeting resolution, the defendants and third parties in such lawsuits is significantly different from the adversary actions between the parties with equal standing. Using the action of rescinding a shareholder meeting resolution of the limited liability company as an example and from the perspectives of the corporate law and procedural law, this article makes a further analysis on the application, legal basis and practice of the Article 2 and Article 3 of the Judicial Interpretation of Corporate Law (IV).

Key Words Company Resolution; Party; Join Action Author

Li Zhigang, Ph. D. in law, Doctoral candidate in industrial economics of Beijing Jiaotong University, senior manager of China Cinda Asset Management Co., Ltd.,.

The Legal Solution of the Land Use Regulatory Reform in China: Thinking on the Strategy of "Ensuring National Food Security" for the Nineteenth Congress *ZHANG Xiangui* • 96 •

Land use control presents a state of operational failure in our country. It is necessary to make a rational review of it and propose reforms and improvements of practical and feasible from the two dimensions of world outlook and methodology. Looking at existing theories and practices, based on the normative context of "right-power" balance, China's current land-use control reform should implement the following "package" program: in terms of conception, we should establish a system of patterns whicih balanced realization of multiple interests appeal; in terms of logical premise, we should actively promote the transformation of China's land planning model from "incremental" to "inventory"; in terms of the key content, we should break through the closed operating structure of agricultural land transfer approval; in terms of the technical route, we should innovate the realization of the "two aggregate indicator controls"; in terms of supporting follow-up, we should effectively promote the construction of a legal system for the redevelopment of stock construction land. Only in this way can it help to break through failure and contribute to the major strategic goal of ensuring the national food security and putting firmly the Chinese people's rice bowls in their hands as set out in the report of the 19th National Congress of CPC.

Key Words Land Use Control; Failure; Land Planning; Approval of Conversion of Agricultural Land; Total Indicators

Zhang Xiangui, Ph. D. in Law, Associate Professor of Law School of Shanghai Maritime University.

On the Application of the Hong Kong Basic Law in the Courts *YANG Xiaonan* • 108 •

The unique character of the mechanism of the interpretation of Hong Kong Basic Law is that according to Article 158 of the Basic Law, the judiciary of the HKSAR enjoys the judicial power, but not the final power of interpreting the Basic Law; while the NPCSC, with this final power, does not apply the Basic Law in the cases in daily life. In practice, there were some controversies around the interaction between the two interpreters. Some scholars thought the distinction between civil law and common law as the main reason for the controversies. However, this observation may ignore the complexity and diversity of the application of the Basic Law. In some cases, the courts adjudicated the cases without interpreting the Basic Law, and thus the NPCSC had the least influence on the result. In some cases, the courts applied the Basic Law in connection with the ICCPR and BORO, and thus the NPCSC's influence was also limited. In the other cases, the

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net